

0009847-40.2021.8.26.0309

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... para ensejar a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Importante salientar que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas para a venda no varejo e no atacado, configurando o tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 0009847-40.2021.8.26.0309

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 0009847-40.2021.8.26.0309

Página nº de

Vistos.

PAOLO ELIAS DE ARAÚJO FELÍCIO, DIEGO DA SILVA, TIAGO CHRISTIAN FONSECA, ROGÉRIO APARECIDO FERREIRA, vulgo "Zelo", ANDERSON APARECIDO FERREIRA e VERCÍDIO BRAZ DE OLIVEIRA NETO, qualificados nos autos, foram denunciados, como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, porque no dia 8

de junho de 2021, por volta de 09h15min, na Rua José Joaquim dos Santos nº 44, Ivoiturucaia, nesta cidade e Comarca de Jundiá, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tinham em depósito, para fim de tráfico, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que causam dependência química, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia, ainda, que, em data e horário incertos, até o dia 8 de junho de 2021, os acusados associaram-se entre si, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Narra a peça inicial que, na data dos fatos, policiais militares receberam delação anônima dando conta da existência de grande quantidade de drogas na residência localizada no endereço acima referido.

Os policiais, então, dirigiram-se ao local e não obtiveram resposta de qualquer morador. Os agentes da autoridade ingressaram no imóvel, oportunidade em que os réus foram surpreendidos enquanto guardavam e tinham em depósito 4 tijolos de "crack", além de 4 balanças de precisão, faca, peneira e dois cadernos contendo anotações típicas do tráfico de entorpecentes.

Observe-se que o processo foi desmembrado em relação ao acusado Paolo, já tendo sido proferida sentença para os corréus.

Notificado e citado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se nove testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado, homologando-se a desistência das testemunhas Diego, Ana Cláudia e Ricardo, a requerimento oral das partes.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a parcial procedência da ação penal, com condenação do réu como incurso no artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade quanto a esse delito. Requereu, ainda, a não aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 do mesmo Diploma Legal e fixação de regime inicial fechado.

A defesa, preliminarmente, requereu a conversão do julgamento em diligência, para instauração do incidente de dependência toxicológica, o que foi deferido (despacho de fls. 370). Em memoriais, arguiu, em preliminar, o reconhecimento da inimputabilidade do réu e, no mérito, buscou a absolvição, sob o fundamento de ausência probatória para a condenação e excesso de acusação.

RELATADO.

DECIDO.

Observo que a diligência requerida pela defesa, em preliminar, foi deferida, sendo instaurado o competente incidente de dependência toxicológica, o qual concluiu que o réu, ao tempo da ação, "Ainda que tenha epilepsia (CID 10: G40) (anomalia neurológica), não estava em crise durante os fatos, não sendo relevante para esta perícia. Destarte, não houve prejuízos no entendimento e na capacidade de determinar-se de acordo com tal, em suas ações em lide" (fls. 94 do apenso - grifei).

E mais, "4. O periciado, em razão da dependência, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Não. 5. O periciado, em razão da dependência, ao tempo do fato, estava privado da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Não". (fls. 95 do apenso - grifei).

Também o fato do perito indicar que o acusado precisa de tratamento ambulatorial não serve para afastar sua imputabilidade.

Assim, a preliminar suscitada pela defesa não merece prosperar, não havendo falar em inimputabilidade.

No mérito, a materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão da droga e dos objetos, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 24/27 e 468/470, os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica; pelo laudo dos objetos (fls. 172/179) e pelos demais documentos acostados aos autos.

No tocante ao delito de tráfico, incontroversa a prova de autoria.

Na fase administrativa, o acusado permaneceu em silêncio.

Em Juízo, negou qualquer envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. Disse que não se recordava dos fatos e não conhecia os demais acusados. Era dependente químico e foi comprar maconha na ocasião para evitar convulsão.

Ocorre que tal negativa restou isolada nos autos e não merece credibilidade.

Corroborando a prova de autoria, as testemunhas Luan Barbosa da Silva e Nelson Barbosa, policiais militares que tomaram parte nas diligências, narraram como se deu o encontro das substâncias entorpecentes e demais objetos em poder dos acusados. Luan esclareceu que recebeu informação via COPOM que em um terreno vizinho ao local dos fatos havia pessoas fazendo uso de drogas na presença de crianças. Dirigiu-se ao local indicado e, em uma das residências existentes no local, visualizou os réus que, ao notarem sua presença, tentaram correr, porém sem êxito, já que não havia rota de fuga. Foram apreendidas diversas porções de "crack" embaladas e em tabletes, embalagens, anotações, balanças e utensílios comumente utilizados no preparo do tóxico. Não conhecia os acusados antes dos fatos. Os agentes permaneceram em silêncio. Os corréus tinham tarefas divididas, já que trabalhavam "numa linha de produção". Explicou que no terreno havia cinco casas e teve sua entrada franqueada no referido terreno por dois moradores do lugar que estavam trabalhando, cujo portão já estava aberto. Sentiu o cheiro do tóxico ao se aproximar do imóvel onde os réus se encontravam, o qual tinha apenas dois cômodos. Bateu na porta da moradia onde os acusados se encontravam "trabalhando" no preparo do entorpecente. A Polícia Militar não utiliza equipamento de filmagem. Nelson, por sua vez, acrescentou que o local descrito na denúncia era utilizado para armazenamento de drogas tanto em pedra bruta como dividida em pequenas porções. O tóxico pesava cerca de 10 quilos. Foi apreendida também uma quantidade muito grande de embalagens. Também não conhecia os acusados antes dos fatos. O aparelho celular operacional que utilizam para anotar as ocorrências não possibilita a filmagem durante as diligências. Foi necessário o arrombamento da porta do imóvel, pois os réus tentaram fugir ao notarem sua presença. Relatou que os moradores que franquearam a entrada no terreno não quiseram se envolver na ocorrência. Os depoimentos colhidos são coerentes, harmônicos e verossimilhantes e não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

Mas não é tudo. Para enfraquecê-lo é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção. E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido é o entendimento do Pretório Excelso, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Celso de Mello DJU 11/04/97).

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (cf. tese nº 06, edição n.º 105 Jurisprudência em teses). E mais, “(...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel^a. Ministra Maria Thereza de Assis Moura 6ª Turma, DJe 1.6.2011).

E no caso dos autos, os relatos dos policiais dão conta da diligência baseada em delação, bem como que ao chegarem ao local, os acusados teriam tentado se evadir, porém sem êxito. Ainda, os agentes da autoridade relataram que, na residência, foram encontradas diversas porções de “crack”, em pedras brutas e prontas para o consumo, em expressiva quantidade, bem como vários objetos destinados ao preparo dessa droga.

Anderson Marcos dos Santos, César Augusto Silva Pretti, Maria Fernanda de Souza Silva Piedade e Francine Araújo Felício, arroladas pela defesa, as duas últimas cunhada e irmã do réu, nada esclareceram sobre os fatos, limitando-se a enaltecer sua boa conduta, bem como que o mesmo apresentava deficiência intelectual, lapsos de memória e epilepsia, com episódios de perda de consciência, bem como fazia uso de medicamentos fortes e drogas para amenizar os efeitos da doença.

Como se vê, o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Importante salientar que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas para a venda no varejo e no atacado, configurando o tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes se caracteriza pela prática de condutas variadas, visto se tratar de tipo misto alternativo. Assim, a adequação do comportamento a qualquer um dos núcleos do tipo penal incriminador implica violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante no momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para tipificação do delito.

Assim, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, são suficientes para a consumação do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido julgado do Superior Tribunal de Justiça: “O crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06, assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o depósito e a guarda dos entorpecentes, hipótese dos autos.” (HC nº 210.746/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe de 01/08/2012).

De outra banda, o delito de associação para o tráfico não restou devidamente comprovado.

Com efeito, não há informações nos autos sobre o tempo de dedicação do réu ao tráfico ilícito de drogas ou se já havia atuado junto com os corréus em momento diverso, não sendo possível afastar-se a possibilidade de único episódio de tráfico praticado conjuntamente por ele.

Assim, não demonstrado o “animus” associativo, de caráter estável e permanente, exigência inerente ao núcleo do tipo inscrito no artigo 35 da Lei 11.343/06 e não sendo bastante a simples concorrência eventual dos agentes, de rigor a absolvição.

Ensina Vicente Grecco Filho “(...) entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para a incidência do

delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Há necessidade de um 'animus associativo', isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (cf. Lei de Drogas Anotada, 1ª ed., 2007, São Paulo, Ed. Saraiva, pág. 120).

Sendo assim, a condenação exige certeza inequívoca, não sendo suficientes meras suposições.

E a dúvida acaba por beneficiar o réu, uma vez que a condenação exige certeza, não bastando, sequer, a alta probabilidade (cf. René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, 1ª ed., Forense, 2002, nº 59, págs. 249-50). Assim também se manifesta a jurisprudência: RT 677/370 e 809/657.

"Considerando, portanto, que o sistema pena se assenta na presunção de inocência do réu, para a condenação da apelada, a prova deveria ser plena e convincente. Para a absolvição, em contrapartida, basta a dúvida, consagrando-se o princípio do 'in dubio pro reo', contido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal" (Apel. Nº 0002313-93.2011.8.26.0374, rel. Des. Toloza Neto, j. de 26/04/2014, v.u.).

"Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP e não no inciso I, do mesmo dispositivo" (RJDTCrimSP, 22/395).

Em outras palavras, "a dúvida é sinônimo de ausência de prova" (cf. Nélson Hungria, Prova Penal, in RF, 138/338).

Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do acusado apenas pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante o exposto, afastada a preliminar, julgo parcialmente PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu PAULO ELIAS DE ARAÚJO FELÍCIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO, da imputação de infringir a norma do artigo 35 do mesmo Diploma Legal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, bem como levando-se em conta a enorme quantidade de droga apreendida em poder dele, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, sendo no percentual de 1/3 (um terço), somando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não é caso de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida, bem como a dedicação do acusado à atividade criminosa (cf. STF, 2ª Turma, HC 115.101/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe- 186, 23/09/2013).

A pena privativa de liberdade ora aplicada será cumprida em regime fechado, uma vez que se trata de crime gravíssimo, eis que a real intenção do traficante é amealhar o maior número de vítimas, comprometendo toda a sociedade.

Observe-se, por oportuno que mesmo a fixação da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é fator determinante para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando a última parte do artigo em comento "estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" tem-se que o regime inicial fechado é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato, uma vez que a conduta do acusado colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.

O réu não poderá apelar em liberdade, porquanto subsistem os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Condene, ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais, no valor de 100

(cem) UFESP's, nos termos dos artigos 804 do Código de Processo Penal; 4º, § 9º da Lei nº 11.608/93 e § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a isenção se aplica somente àqueles beneficiários da assistência judiciária. Aplica-se o aludido dispositivo legal, de forma subsidiária aos processos criminais, porquanto inexistente no Código de Processo Penal artigo referente à cobrança das taxas judiciárias processuais, observando-se que o artigo 804 do Código de Processo Penal limita-se a indicar que o vencido será condenado às custas, sem especificação do procedimento atinente.

No tocante à exigibilidade da dívida, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, "(...) 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido". (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 16/12/2016). Assim, fica o réu PAULO ELIAS DE ARAÚJO FELÍCIO, condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançados no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 16 de setembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito